

1039892-36.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Repetição de indébito

Magistrado: Maricy Maraldi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 10ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ICMS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

10ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, 8º andar -, Centro - CEP 01501-020, Fone: 3242-2333r2031/, São Paulo-SP - E-mail: sp10faz@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1039892-36.2020.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Sindsider - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Vistos,

Sindsider - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos(m) ação cível pelo procedimento comum contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo aduzindo, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical, representante da categoria do ramo siderúrgico em âmbito nacional, sendo que seus filiados são contribuintes do ICMS. Acrescenta que seus filiados são adquirentes contumaz de energia elétrica e, em razão da dimensão de seu consumo, celebram contratos diferenciados junto às empresas concessionárias de energia elétrica em âmbito nacional, a partir dos quais parcela de sua distribuição de energia elétrica mensal refere-se ao consumo medido em KWh, e a outra parcela à demanda por potência, medida em KW. Alega que há períodos em que seus filiados consomem quantidades menores de energia, razão pela qual a quantidade de demanda contratada disponibilizada pela concessionária nem sempre é integralmente utilizada. Esclarece que, no contrato, há previsão da cobrança de valor sob o título de demanda contratada. Ocorre que, nas faturas mensais de energia elétrica, constam a incidência de ICMS sobre a energia consumida e também sobre o valor pago sob o título de demanda contratada. Aduz que a ré está exigindo ICMS sobre base de cálculo superior àquela permitida pela legislação pátria, vez que o tributo não está sendo cobrado apenas sobre o valor da mercadoria/serviço efetivamente utilizado, mas integralmente sobre a demanda contratada por potência. Desse modo, requer: (i) a concessão da liminar, para determinar que a ré se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS a totalidade da demanda contratada e, que passe a exigir a cobrança do ICMS somente sobre a demanda efetivamente utilizada de energia elétrica dos associados do autor; (ii) a procedência total da ação, para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as empresas

associadas do autor e o Estado Requerido quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre a totalidade do contrato de demanda de potência de energia elétrica não utilizada, definindo-se a base de cálculo do referido tributo, em tais operações, apenas sobre a demanda de potência de energia elétrica efetivamente consumida, bem como impedindo-se a imposição de quaisquer medidas coercitivas relacionadas à sua cobrança. Pugna, ainda, pela condenação da ré à restituição e/ou compensação às empresas filiadas do autor dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos cinco anos anteriores à distribuição do feito, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos da legislação vigente, que será apurado ao final da demanda. Atribui à causa o valor de R\$ 10.000,00 (fls. 1/32).

Juntou, à inicial, procuração, documentos e custas (fls. 33/86).

Indeferida a liminar (fl. 87). Foi interposto agravo de instrumentos, ao qual foi dado provimento (fls. 142/144).

Citada, a ré apresentou defesa na forma de contestação (fls. 92/119), defendendo a legalidade da cobrança, sustentando a improcedência do pedido, ao argumento de que o autor parte de premissa equivocada, pois afirma que seus afiliados estão recolhendo ICMS sobre energia elétrica que não consumiram, quando na realidade, a energia elétrica que está sendo cobrada foi-lhes integralmente fornecida. Salienta que a demanda contratada não é energia elétrica posta à disposição da contratante, mas sim, fornecida, e como tal, legitimamente cobrada. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Instados sobre provas (fl. 120), a ré requer o julgamento antecipado da lide (fls. 125/126). O autor informa que não possui provas a produzir (fls. 128/129).

Houve réplica (fls. 130/140).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO. DECIDO.

O julgamento antecipado é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é exclusivamente de direito.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, c.c. Pedido de Repetição de Indébito, na qual a parte autora, entidade sindical representante da categoria do ramo siderúrgico em âmbito nacional, objetiva o reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS, com o qual seus afiliados vem arcando, sobre o fornecimento de energia elétrica no "contrato de reserva de demanda ou potência", devendo a cobrança ficar adstrita apenas a energia que foi consumida e integralmente fornecida e não sobre a demanda contratada. Aduz o autor que a ré está embutindo indevidamente no valor da cobrança do ICMS energia elétrica que não foi consumida, baseada exclusivamente na existência de "contrato de demanda reservada ou de potência de energia elétrica" firmado entre os afiliados do autor e a concessionária de energia. Desta feita, insurge-se o autor em razão do fato de seus afiliados estarem arcando com o pagamento de ICMS embutido na conta de fornecimento de energia elétrica, decorrente de contrato de reserva de demanda ou potência, base de cálculo que considera equivocada, na medida em que estão pagando por energia que não consumiram efetivamente.

Em que pesem as razões da requerida Fazenda do Estado, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante julgamento afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 63, REsp 960.476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.03.2009), que firmou entendimento no sentido de que "a simples formalização de contrato de fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria, razão por que não pode o ICMS incidir

sobre a denominada 'demanda contratada' O tributo incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor."

Nesse sentido, o Recurso Especial nº 343.952/MG, REL. MIN. ELIANA CALMON, j. 05.02.2002; Recurso Especial nº 647.553/ES, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, j. 05.04.2005; e Recurso Especial nº 960.476/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 11.03.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. Transcrevemos:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do Resp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa'. 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que 'não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência'. Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. Estes julgados do Superior Tribunal de Justiça resultaram na Súmula 391, segundo a qual "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ICMS. CRITÉRIO DE DEMANDA RESERVADA OU CONTRATADA. TRIBUTO QUE SOMENTE INCIDE SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. I - Quedou-se o recorrente agravante em afirmar, genericamente, ter a Corte ordinária deixado de se pronunciar sobre dispositivos legais, sem demonstrar por que esta análise seria imprescindível à solução da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, outro resultado ao julgamento. Assim sendo, evidente incidir a Súmula n. 284/STF, a inviabilizar o especial, no particular. II - Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "o fato gerador do ICMS dá-se com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é presumida por contrato em que se estabelece uma demanda junto à fornecedora de energia elétrica, sem a sua efetiva utilização" (Resp nº 825.350/MT, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 26.05.2006, p. 250). III - Outro precedente citado: Resp nº 806.281/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 11.05.2006, p. 171. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no Resp nº 855.929/SC Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO 1ª Turma Data do Julgamento: 19.09.2006 grifamos).

Sobre o valor a restituir cumpre que se adicione correção monetária desde o

desembolso, que propriamente nada acrescenta ao capital, apenas preservando o valor da moeda, de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado. A partir de então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença").

Assim, sendo ilegítima a exação, devem ser restituídos os valores indevidamente exigidos a esse título, observada a prescrição quinquenal, interregno cujos comprovantes de pagamentos serão oportunamente apresentados, sendo de rigor a procedência da ação.

Isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, e extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, para reconhecer e declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica não utilizada, devendo a requerida abster-se de novas cobrança, e que o valor pago a mais seja retirado, definitivamente, nas próximas faturas de consumo de energia elétrica dos associados à entidade sindical, tornando definitivo o acórdão que deferiu a tutela antecipada, condenando-se, ainda, a requerida a restituir os valores indevidamente cobrados dos associados à entidade sindical, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

Sobre os valores incidirão juros e correção monetária nos termos supra fixados.

Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do valor da condenação a ser apurado quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).

P.R.I.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

Maricy Maraldi
Juiz(a) de Direito

O presente documento é assinado digitalmente, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.